

1500206-41.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIS BASTOS

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... droga apreendida era destinada ao tráfico. Ao Estado-acusador incumbe demonstrar a configuração do tráfico, que não ocorre pelo simples fato dos réus terem comprado e estarem na posse de entorpecente. Em suma, se a pessoa é encontrada com drogas, cabe ao Ministério Público comprovar que o entorpecente era destinado ao tráfico. Não fazendo esta prova, prevalece a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

1ª Vara Criminal

Av. Peixoto Gomide, s/nº, ., Centro - CEP 18200-160, Fone: (15) 3511-2411,

Itapetininga-SP - E-mail: Itapet1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500206-41.2021.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2035247/2021 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Itapetininga, 832/2021 -

Seccional - Itapetininga

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO DOS SANTOS SENNE

Aos 15 de março de 2022, às 14:45h, na sala de audiências da 1ª Vara Criminal do Foro de Itapetininga, Comarca de Itapetininga, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). ANDRE LUIS BASTOS, comigo Escrevente ao final nomeado. Presentes o acusado GUSTAVO DOS SANTOS SENNE acompanhado de seu defensor público, Dr(a). Mariela Moni Marins Tozetto, e o DD. Promotor de Justiça Dr. Carlos Renato Ferreira Zanini. Antes de iniciados os trabalhos a defensora pública entrevistou-se com o réu, pela plataforma da Microsoft Teams, em contato reservado. Pelo MM. Juiz foi dito que: audiência realizada por videoconferência, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, sendo que os depoimentos colhidos nesta data foram importados e vinculados ao SAJ. Em seguida, com as formalidades legais e com a anuência das partes e do réu, passou o MM. Juiz a tomar os depoimentos, todos colhidos através da ferramenta Microsoft Teams, os quais foram gravados de forma individual e ao final, identificados, para que não houvesse risco de perda de gravação caso a solenidade fosse gravada apenas em arquivo único. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi colhido o

interrogatório do réu e em seguida colhidos os depoimentos de 02 (duas) testemunhas de acusação, arroladas em comum com a defesa do réu. Indagado novamente o réu se queria acrescentar algo em seu depoimento, o mesmo disse que não. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal e dava a palavra às partes para apresentação de alegações finais. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, pelo mesmo foi dito: MM. Juiz: O réu foi denunciado como incurso no art. 33 "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na exordial, trazia consigo, para fins de tráfico, droga consistente em 11,72g (onze gramas e setenta e dois centigramas) de crack (cocaína petrificada), divididos em 83 (oitenta e três) porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 08 e laudos toxicológicos de fls. 15/16 e 66/68. Oferecida denúncia, o réu foi notificado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida e o réu foi citado. Durante a audiência de instrução e julgamento as testemunhas foram ouvidas. O réu foi interrogado e a instrução foi encerrada. É a síntese do necessário. Douto Julgador, o pedido deve ser julgado PROCEDENTE para CONDENAR o réu nos exatos termos propostos na denúncia. Narra a denúncia que, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina no local dos fatos, quando avistaram o denunciado em atitudes suspeitas remexendo em um monte de pedriscos, o qual, ao avistar a aproximação da viatura, deixou o local apressadamente, porém, acabou sendo detido. Em poder do denunciado foi apreendida uma pedra de crack na mão direita, além da quantia de R\$ 387,00 no bolso da bermuda que ele trajava. Outras 82 (oitenta e duas) pedras de crack, que estavam numa embalagem plástica, foram localizadas no local em que ele estava vasculhando, momentos antes. Nestas circunstâncias, o denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia e autuado em flagrante delito. Assim, as circunstâncias da prisão, a quantidade e forma de acondicionamento da droga bem evidenciam que efetivamente se destinavam ao fornecimento para o consumo de terceiros. A materialidade da infração penal está demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito, do boletim de ocorrência, do auto de exibição e apreensão, do laudo de constatação provisória e do laudo de exame químico-toxicológico. Quanto à autoria, também não restou a menor dúvida. Sob o crivo do contraditório, o réu admitiu que estava comercializando droga e que o dinheiro que trazia consigo era da venda de droga. Disse que estava com apenas uma porção de droga e negou a propriedade das demais porções de droga localizadas pelos policiais. Em que pese o esforço empreendido pelo acusado, na tentativa de eximir-se da responsabilidade penal, verifica-se que a versão apresentada por ele está ilhada nos autos, cercada pelos demais elementos de prova amealhados no curso da instrução criminal, motivo pelo qual não merece credibilidade. A prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório, confirmou a fato descrito da denúncia, fornecendo firme base para a prolação da sentença condenatória, conforme se depreende dos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais que procederam a abordagem do réu. As testemunhas ouvidas confirmaram o teor da denúncia, relatando que avistaram o réu e resolveram abordá-lo e em seu poder localizaram uma pedra de crack e dinheiro proveniente da venda de droga. Em seguida, foram até o local onde avistaram o réu inicialmente e localizaram as demais porções de droga. Acrescento que, relativamente aos depoimentos de agentes públicos, a jurisprudência sabiamente sedimentou a questão, reconhecendo o valor do depoimento daqueles, quando os autos não apresentem elementos que indiquem que tal prova não deva ser considerada. Ora, seria uma manifesta contradição o Estado credenciar agentes para atuar na área da segurança pública e investigar a prática de crimes e não acreditar em seus depoimentos em Juízo, cabendo lembrar que os policiais também são devidamente compromissados. Não se pode olvidar a presunção de lisura dos atos praticados por policiais, que, até prova em contrário (que nestes autos não foi produzida pelo réu), deve prevalecer. Aliás, nestes termos pronunciam-se os nossos Pretórios: "O depoimento de policial militar, que efetuou a prisão em flagrante do agente, se reveste de especial valoração probatória pela premissa de que o servidor público, investido de autoridade, tem o dever funcional de contribuir para a apuração da verdade real e

aplicação da lei penal" (STF - HC 119067 PR. Relator Min. LUIZ FUX. Julgamento: 28/08/2013. Publicação: DJe-171, 02/09/2013). "Neste compasso, ou seja, em relação à palavra dos policiais, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento." (STJ - AREsp 302955 SP 2013/0065939-3. Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Publicação: DJ 15/10/2014). Além da prova oral, outra circunstância que permite deduzir que as substâncias se destinavam à mercancia são justamente a quantidade, forma de acondicionamento e apreensão de valores em dinheiro, o que não deixa dúvida de que o réu se dedicava ao tráfico ilícito de entorpecentes. Nestes termos, demonstradas a autoria e a materialidade da infração penal descrita na denúncia, a condenação do réu nos termos acima propostos, é medida que se impõe. Diante de todo o exposto, aguardo seja a ação penal julgada PROCEDENTE para que o réu seja CONDENADO nos termos da denúncia, decretando-se o perdimento do valor apreendido, produto do tráfico. Dada a palavra à Defensora do réu, pela mesma foi dito: MM. Juiz: O Acusado responde por este juízo pela suposta prática de tráfico de entorpecentes. Após a regular tramitação do feito, foi colhido o depoimento das testemunhas e o réu foi interrogado. Finda a instrução, o i. representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia. Sem razão, contudo. DA PROVA ORAL COLHIDA. Ao ser interrogado o réu narrou que tinha consigo uma pedra de crack e o dinheiro apreendido. Narrou que o dinheiro era proveniente da venda de entorpecentes. Narrou que os entorpecentes localizados nos "pedriscos" não lhe pertenciam e não foi abordado naquele local. A testemunha PM Danilo narrou que viram o réu mexendo em pedrisco, ele foi abordado e localizado com ele uma pedra de crack e dinheiro. Informou que o réu confessou que realmente estava realizando o tráfico de drogas. No mesmo sentido, a declaração do PM Neto. FUNDAMENTOS JURÍDICOS. Deve haver a absolvição da imputação de tráfico de entorpecentes, porque não há prova de traficância. Sobre a necessidade de prova segura da traficância, aplica-se o seguinte entendimento do Supremo Tribunal Federal: "O réu não tem o dever de demonstrar que a droga encontrada consigo seria utilizada apenas para consumo próprio. Cabe à acusação comprovar os elementos do tipo penal, ou seja, que a droga apreendida era destinada ao tráfico. Ao Estado-acusador incumbe demonstrar a configuração do tráfico, que não ocorre pelo simples fato dos réus terem comprado e estarem na posse de entorpecente. Em suma, se a pessoa é encontrada com drogas, cabe ao Ministério Público comprovar que o entorpecente era destinado ao tráfico. Não fazendo esta prova, prevalece a versão do réu de que a droga era para consumo próprio". (STF. 1ª Turma. HC 107448/MG, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, 18.6.2013 - Info 711). Não foi produzida, nestes autos, prova suficiente de que a droga apreendida se destinasse ao tráfico. Mesmo quando a droga é apreendida em grande quantidade (o que não é o caso dos autos), não se pode condenar sem prova da traficância. Neste sentido: "Sendo grande a quantidade de tóxico apreendida, induz seu tráfico. Mas ninguém pode ser condenado por simples presunção, motivo por que para o reconhecimento do delito se exige prova segura e concludente da traficância" (TJSP, Ac. 35.505-3, rel. Silva Leme, RT 603/316). Ainda, é caso de absolvição diante da contaminação da prova. Conforme se verifica dos autos, não foi observada a incomunicabilidade entre as testemunhas de acusação, já que ambas estavam no mesmo ambiente.

Percebe-se que além da fragilidade probatória, o rompimento de regra processual basilar que versa sobre a incomunicabilidade de testemunhas, o que também deve conduzir à absolvição do réu. Desta forma, conclui-se insuficiente a prova da acusação, sendo impositiva a absolvição. DOSIMETRIA. Superadas as teses de mérito e de desclassificação, devem ser observadas as seguintes questões no tocante à concretização da pena. Na primeira fase, a pena deve ser fixada no mínimo legal. Foi apreendido com o Autor apenas pouca quantidade de droga, substâncias que o réu faz uso. Desta forma, não estão previstas as circunstâncias de exasperação da

pena base mencionadas no art. 42 da Lei de Drogas. Na segunda fase, incide a atenuante da idade do Acusado, que tinha somente dezenove anos na época dos fatos. Incide, ainda, a atenuante da confissão, que deve ser valorada, mormente se for utilizada como fundamento para a condenação (Súmula 545/STJ). Na terceira fase, deve incidir a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Necessária a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em seu percentual máximo, eis que o acusado é primário, tem bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e nem integram organização criminosa. "A ausência de provas do envolvimento em atividades criminosas ou da participação em organização criminosa deve ser interpretada em benefício do acusado e, por conseguinte, não é suficiente para afastar a aplicação da causa de redução da pena. Incidência do princípio da presunção de inocência e da regra do in dubio pro reo" (STF, 2ª Turma, HC 103.225/RN, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 22/11/2011). Acerca da quantidade e qualidade da droga apreendida e a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, decidiu o STF que a: "Quantidade e qualidade da droga apreendida é circunstância que deve ser sopesada na primeira fase de individualização da pena, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, sendo impróprio invocá-la por ocasião da escolha do fator de redução previsto no §4º do art. 33, sob pena de bis in idem" (STF, 2ª Turma, RHC 111.440/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/05/2012). Sobre o percentual aplicável: "O juiz, no exercício de suas funções judicantes, atendendo ao princípio do livre convencimento motivado, deve fundamentar a não aplicação do percentual de 2/3 de redução, sob pena de violação do art. 93, IX, da CF/88, uma vez que é direito subjetivo do réu a redução prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, desde que preenchidos os requisitos previstos no referido parágrafo" (STJ, 5ª Turma, HC 115.473/SP, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 02/02/2009. REGIME INICIAL e PENA ALTERNATIVA. Quanto ao regime inicial, nos termos do artigo 33 do Código Penal, requer seja fixado o regime aberto para cumprimento da pena. Isso porque, a fixação de regime fechado como decorrência automática do disposto no artigo 2º da Lei n. 8.072/90 contraria o princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Cumpre ressaltar que o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, durante o julgamento do Habeas Corpus nº 111.840, em sessão realizada no dia 27 de junho de 2012, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 11.464/07, o qual prevê que a pena por crime hediondo (inclusive tráfico de drogas) será cumprida, inicialmente, em regime fechado. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 596.603/SP assentou o entendimento de que condenados por tráfico privilegiado possuem direito subjetivo ao cumprimento da pena em regime inicialmente aberto. Destarte de rigor a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena. Cabível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista que o artigo 44 foi considerado inconstitucional pelo E. STF (HC n. 97.256/RS), o que motivou a expedição da Resolução n. 05, de 2012, do Senado Federal, suspendendo, nos termos do art. 52, X, da CF a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06" No mesmo sentido foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC n. 596.603/SP. Diante do exposto, requer sejam acolhidas as teses defensivas, nos termos da fundamentação supra. Por fim, requer seja concedido o direito de recorrer em liberdade, bem como a gratuidade de justiça, com isenção de custas processuais, por se tratar de pessoa hipossuficiente nos termos da lei. A seguir pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: GUSTAVO DOS SANTOS SENNE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/06, sob a acusação de que, no dia 06 de fevereiro de 2021, por volta das 11:52hrs, na Rua Manoel Henrique Peixoto, trazia consigo, para fins de tráfico, 83 porções de maconha. O feito foi regularmente processado encerrando-se a instrução nesta data com alegações finais do MP e da Defesa. Eis, em síntese, o relatório. FUNDAMENTO E DECIDIDO. O presente processo foi instaurado para apuração da responsabilidade penal do réu no tocante à prática do delito de tráfico ilegal de entorpecentes. A materialidade restou incontroversa ante a apreensão da droga e o laudo acostado aos autos. O réu confessou que estava

traficando no local porém negou que a droga encontrada no monte de pedriscos fosse de sua propriedade, admitindo a propriedade somente da porção que estava em suas mãos. Os policiais declararam que em patrulhamento pelo local viram o réu mexendo num monte de pedriscos; que ao perceber a viatura ele saiu andando o que motivou a abordagem; que com ele havia uma pedra de crack nas mãos e uma quantia em dinheiro; que no local onde ele mexia, um monte de pedriscos, foram encontradas mais 82 pedras de crack. Pois bem, finalizada a instrução, temos que o conjunto probatório leva à conclusão de que o réu é responsável pela prática do delito; a assertiva é lógica e harmoniza-se com os elementos colhidos no decorrer do feito. A quantia de droga encontrada, as circunstâncias da prisão e a declarações do policial evidenciam a finalidade de tráfico. A prova oral colhida, à luz do contraditório e as demais provas acostadas aos autos, formam um conjunto apto à formação de um juízo de convencimento quanto ao tráfico exercido pelo réu. Vale citar: "Adquirir, guardar ou trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, substância entorpecente, são condutas comuns aos delitos de tráfico ilícito e uso indevido, do que resulta, pelo princípio da exclusão, quando não se tratar de uso indevido, reconhecer o narcotráfico. Caracteriza o delito de tráfico ilícito de substância entorpecente trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, maconha e cloridrato de cocaína, em doses unitárias, de pequenos embrulhos, embalagem usual do varejo das drogas" (TJRJ - AC 1.185/93 - Rel. Enéas Machado Cotta - TDTJRJ 23/288). Vale dizer que a lei pune o tráfico ilícito de entorpecente em qualquer de suas condutas, típicas e exclusivas. Vale, ainda, mencionar que nenhuma restrição merecem os depoimentos de policiais, mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada. Nesse sentido: "nenhum impedimento legal existe ao testemunho de investigadores e pessoas ligadas à polícia. Seus depoimentos devem ser considerados, examinados e pesados em cada caso, como o de outra testemunha qualquer. Nunca, porém, sumariamente afastados como de todo imprestáveis. Desde que verossímeis, coerentes e não desmentidos pelo restante da prova, podem servir de base à decisão condenatória." (Ap.Crim. 103.701 TJSP). " a simples condição de policial não torna a testemunha suspeita ou impedida" (STF - RT 68/64). " não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contra-senso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito. " (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221). Por outro lado, considerando que o réu é tecnicamente primário, é possível reconhecer a favor dele a causa de diminuição de pena do art. 33 parág. 4º, o que será feito no momento processual adequado. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado narrada na denúncia e CONDENO o réu GUSTAVO DOS SANTOS SENNE, qualificado nos autos, como incurso no art. 33 parág 4º da Lei 11.343/06. Ante a condenação, custas pelo réu, ficando suspensa a exigibilidade de pagamento em face dos benefícios da justiça gratuita deferidos nos autos. Fica decretado o perdimento dos bens e objetos apreendidos nos termos da Lei de Tóxicos. DOSIMETRIA DA PENA. Atento aos critérios estipulados no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em seu mínimo legal, a saber: CINCO ANOS DE RECLUSÃO e multa de QUINHENTOS DIAS MULTA, cada qual no seu mínimo legal. Não existem circunstâncias agravantes. Presente duas atenuantes decorrentes da confissão e da menoridade cuja consideração resta prejudicada em face da fixação da base em seu mínimo. Inexistem causas de aumento de pena. Presente uma causa de diminuição de pena, prevista no art. 33 parág. 4º da Lei 11.343/06, eis que o réu preenche os requisitos ali exigidos, diminuo em 2/3 a pena até agora calculada, chegando-se ao "quantum" de UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO e multa de CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS MULTA. Não havendo incidência de qualquer outro instituto penal a influenciar na quantificação da reprimenda torno DEFINITIVA A PENA DE UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO e multa de CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS MULTA, cada qual em seu patamar mínimo. Nos termos do art. 44 do Código penal, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE

LIBERDADE POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE e MULTA DE DEZ DIAS MULTA. Ante a substituição retro operada, inviável a suspensão condicional da pena. Fixo, como regime inicial de cumprimento de pena para o caso de conversão, o REGIME ABERTO. O réu foi colocado em liberdade no decorrer do feito e tal situação deve subsistir. Oportunamente, esgotadas as vias ordinárias, providencie-se o necessário para efetivo cumprimento da sanção imposta, arquivando-se o feito com as cautelas devidas. Publicada em audiência, saem os presentes intimados, nos termos do art. 392 do CPP. Cumpra-se. O resultado da presente audiência foi informado às partes, saindo os presentes intimados, dispensada a assinatura em razão de tratar-se de processo digital. O réu declara estar residindo no bairro do Bocó, Guareí-SP (próximo à Usina Shinodo). Nada mais. Eu, ALINE CRISTIANE ROCHA MEIRA RAMOS, escrevente, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIS BASTOS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA